

1502621-28.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143696/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 18156510 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2783/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2143696 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EU2BFl1KxqN0r7XwnjtikYBYuLJ684oecbo_65bgZhYcg?e=fvGOKc)

EU2BFl1KxqN0r7XwnjtikYBYuLJ684oecbo_65bgZhYcg?e=fvGOKc

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502621-28.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000615

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143696/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 18156510 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2783/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2143696 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS GABRIEL NAZZI

Em 20 de julho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Fernando Masseli Helene, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado MARCOS GABRIEL NAZZI; o acusado referido; e as testemunhas André Luiz Pavan dos Santos e Fábio Augusto Martini, que prestaram seus depoimentos. A Defensora informou que desiste das oitivas das testemunhas Jacira e Noemy, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. MARCOS GABRIEL NAZZI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O processo foi suspenso no artigo 366 do Código de Processo Penal (pág. 193) em 14 de março de 2022. O acusado foi

notificado e apresentou defesa prévia (p. 253-258). A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022. (p. 259-260) e o réu foi citado (p. 292). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias, laudo pericial, além da prova oral. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o réu confirmou o tráfico, mas alegou que os policiais invadiram a sua casa sem sua autorização. A confissão do réu, embora qualificada, foi confirmada pelas provas produzidas. Os policiais militares André e Fábio relataram a abordagem do réu em frente à casa dele, e o encontro de drogas, tanto com o réu quanto em sua residência, além de balança e apetrechos para fracionamento. Pois bem. Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial. O réu, na fase inquisitiva (pg. 9), confirmou que estava na frente do imóvel vendendo "crack" a outro indivíduo quando a viatura se aproximou. Tal relato foi confirmado em juízo pelos policiais militares. Eles declararam que visualizaram o réu e outro indivíduo em frente ao imóvel em situação indicativa de tráfico. Na posse do réu foi encontrado uma porção de "crack" e uma gilete, além de dinheiro. O outro indivíduo empreendeu fuga. Nas proximidades também havia uma bolsa com mais drogas. Tais circunstâncias revelavam fundada suspeita da situação de flagrância e autorizavam o ingresso no local. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio". (STJ, HC 415.332-SP, 6ªT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julg. 16/08/2018). Os policiais apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem, do encontro dos entorpecentes com o réu e não há qualquer elemento seguro capaz de afastar as sobreditas versões. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). No mais, o réu admitiu o tráfico, apesar de ter sustentado ilegalidade na atuação policial, alegação já rechaçada. E, ainda que ele seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e

frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, pelo que não podem ser acolhidas as teses defensivas. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, verifico que a pena-base deve ser majorada, considerando a natureza de parte do entorpecente apreendido - "crack", substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), pelo que mantenho a pena no patamar anterior. A confissão, como já mencionado, foi qualificada. Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3 para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, que se torna definitiva. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e dos motivos esposados na primeira fase. Por fim, consigno que, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a

progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu MARCOS GABRIEL NAZZI, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, pois continuam presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar. Não se olvide que o acusado foi colocado em liberdade após ser preso em flagrante, mas descumpriu as medidas cautelares, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva e reforça a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declare o perdimento dos bens apreendidos. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público, o Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).

Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: MARCOS GABRIEL NAZZI

CPF: 565.887.408-40, RG: 60985128, RJI: 213922405-80

Data De Nascimento: 27/01/2003

Filiação: pai MARCOS ROGERIO NAZZI, mãe ANGELA CRISTINA GUILHERME

Residência: Rua Dr. João Alberto Guilar Mamede, 840, Cidade Alta, Jaú/SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.